

1584260-74.2022.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... 4º, da Lei n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaio/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

1584260-74.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1584260-74.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RODRIGO SOARES LEITE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO FERRAZ DE CAMARGO LOPASSO

Vistos.

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu RODRIGO SOARES LEITE, qualificado a fls. 36, porque, 12 de novembro de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Silvio Manfred, nº 300, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso, com unidade de propósitos e designios com indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Y/Yamaha, cor vermelha, ainda sem emplacamento, um aparelho celular, marca Samsung, além de uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, bens estes pertencentes à vítima Wesley Herbert de Oliveira.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, após observarem detidamente a motocicleta acima descrita, de propriedade da vítima, estacionada defronte a uma igreja, o denunciado e seu comparsa ainda não identificado ajustaram a prática de um crime de roubo.

Para tanto, aguardaram a vítima e sua esposa deixarem a igreja no citado veículo, oportunidade em que, a bordo de uma motocicleta de cor preta, placas não identificadas, passaram a segui-las.

Na sequência, aproveitando-se que o ofendido Wesley diminuiu a velocidade da motocicleta para passar em uma lombada, fecharam a passagem do veículo ocupado pelas vítimas.

Ato contínuo, RODRIGO desceu da motocicleta e, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que as vítimas entregassem o veículo e demais pertences pessoais.

Então, de posse do aparelho celular e da carteira de Wesley, o denunciado se evadiu do local na condução da motocicleta subtraída, tendo sido seguido por seu parceiro, que fugiu na outra motocicleta.

Ocorre que as vítimas tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança da igreja que frequentavam, ocasião em que puderam visualizar as características dos meliantes, tendo Wesley, poucos dias após os fatos, avistado o denunciado na barbearia localizada ao lado da igreja e o reconhecido, imediatamente, como sendo um dos roubadores.

Tal informação, juntamente com as imagens das câmeras de segurança da igreja, foram levadas ao conhecimento da Polícia Civil. As vítimas, então, foram acionadas a comparecer na Delegacia de Polícia, onde realizaram o reconhecimento pessoal do denunciado como sendo um dos autores do delito (cf. autos a fls. 34 e 35).

Interrogado em sede policial, o denunciado confirmou que era um dos indivíduos que aparecem nas imagens, mas negou a prática do crime (fl. 38)

Denúncia recebida às fls. 57/58.

Citado pessoalmente (fl. 117), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 103/116).

Ratificado recebimento da denúncia às fls.122/123.

Em audiência de instrução, o acusado foi interrogado após a oitiva das vítimas e duas testemunhas (fls. 156/160).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia. (fls. 156/160).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; outrossim, apresentou teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 156/160).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de roubo biqualeficado ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, relatório de investigações de fls. 10/12, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

As vítimas Janaína e Welsey, ouvidos em Juízo, narraram o assalto da mesma forma como descrita na denúncia e reconheceram o acusado com absoluta certeza como um dos roubadores, assim como fizeram em sede policial (fls. 34/35)

Em resumo, narraram que na noite dos fatos, após saírem da igreja, por volta das 23h, foram abordados por dois indivíduos que estavam em uma moto. RODRIGO era o garupa e anunciou o assalto, armado. Em seguida, o acusado se evadiu do local na condução da motocicleta subtraída, tendo sido seguido por seu parceiro, que fugiu na outra moto. Dias depois, o bispo da igreja mostrou os vídeos da câmera de segurança, onde foi possível ver dois indivíduos olhando a moto estacionada no dia do assalto, cobiçando-a. A moto roubada era uma edição limitada, por isso chamava a atenção. Ao passar em frente a barbearia próxima a igreja, reconheceram Rodrigo das filmagens e do assalto. Era o mesmo indivíduo. Informaram à polícia que tinham visto os vídeos das câmeras de segurança da igreja e a barbearia onde o réu havia sido identificado. Na delegacia realizaram o reconhecimento formal do réu. No assalto, os roubadores estavam de capacete, mas com a viseira aberta.

Wesley disse que: "Foi vítima do assalto. Estava na motocicleta com sua esposa. O assalto ocorreu por volta de 23h/23h30 da noite. Estavam indo para casa. Eram dois assaltantes. Um deles estava armado. Os indivíduos estavam em outra moto. Ao frear para passar na lombada foi abordado. Encostaram a moto ao lado e pediram para descerem informando o assalto. Quando estava na igreja, foi avisado por um líder que dois indivíduos estavam observando a moto estacionada, cobiçando-a. O assaltante da garupa estava armado. Foi levado também o celular com o cartão de crédito. Cada assaltante foi em uma moto. Minutos após o assalto, o cartão foi usado em uma adega. Os pertences não foram encontrados. O prejuízo foi de cerca de sete mil reais. O assalto ocorreu na sexta-feira. No domingo o bispo da igreja mostrou os vídeos da câmera de segurança, onde foi possível ver dois indivíduos olhando a moto estacionada no dia do assalto. A moto roubada era uma edição limitada. Ao passar em frente a barbearia próxima a igreja reconheceu Rodrigo das filmagens e do assalto. Informou à polícia que tinha visto os vídeos e a localidade do indivíduo que havia identificado. Na delegacia realizou o reconhecimento formal do réu. Conhecia Rodrigo apenas de vista. No assalto, os indivíduos estavam de capacete, com a viseira aberta. Na delegacia, reconheceu Rodrigo principalmente pela cor e características físicas. Em audiência, reconhece novamente o acusado. Rodrigo era o indivíduo que estava armado na garupa. Janaína também reconheceu Rodrigo nas ocasiões em que o viram. Não teve acesso aos detalhes do processo. Buscou informações de Leonardo no Instagram, onde verificou que ele tinha uma moto igual, porém em modelo mais antigo. Não sabe informar se a mesma moto foi utilizada no assalto. Na barbearia, reconheceu Rodrigo pelo assalto".

Janaína deu a mesma versão: " Foi vítima do assalto. É esposa de Wesley. O assalto ocorreu entre 23h/23h30. Eram dois assaltantes. Estavam em uma moto. O indivíduo da garupa estava armado. Os assaltantes os abordaram e mandaram descer. Não foram levados pertences pessoais seus. No dia não houveram prisões. No domingo pela manhã estava indo ao mercado com Wesley, quando passaram em frente a barbearia e reconheceu Rodrigo como um dos assaltantes. Realizou o reconhecimento formal do réu na delegacia. Em audiência reconhece novamente o acusado. No momento do assalto os assaltantes estavam de capacete com a viseira aberta. Rodrigo era o assaltante na garupa que ordenou que descessem da moto. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Assistiu ao vídeo das câmeras de segurança da igreja. No vídeo é possível perceber

que os indivíduos olharam para a moto de forma a cobiçá-la. Na delegacia havia outras três pessoas além de Rodrigo na sala de reconhecimento”.

Em se tratando de roubo, a(s) palavra(s) da(s) vítima(s) tem sumo valor probatório, pois seu único interesse é apontar o verdadeiro acusado - ou acusados - e, aliada a outros elementos de prova, autoriza o decreto condenatório.

Assim é o entendimento:

Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância, (TACrim/SP 91/407 e 86/433)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TACrim/SP 90/362).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e atinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (94:341)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (RT 484:320).

Observe-se, aliás, a inexistência de qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal operado pelas vítimas, seja na Delegacia, seja em Juízo.

As formalidades descritas no art. 226, do CPP não são essenciais, mas meras recomendações.

A propósito:

PROVA - Reconhecimento de pessoa - Inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Nulidade - Inocorrência - A prioridade na hipótese é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão "se possível", o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade - Procedimento, portanto, que é recomendável e não exigível - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 1.085.254-3/3 - São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Rodrigo Augusto de Oliveira - 04.04.08 - M. V. - Voto n. 1.080)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Realização sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - Nulidade - Não ocorrência: - A realização de reconhecimento pessoal sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não tem o condão de acarretar a nulidade do ato. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.387.403/2 - Ribeirão Preto - 10ª Câmara - Relator: Ricardo Feitosa - 1º. 10.2003 - V. U. (Voto nº 7.167) (TACrim - Ementário nº 50, Fevereiro/2004, pág. 28)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP - Irrelevância: - A Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP não gera a nulidade do feito, pois o reconhecimento realizado em audiência não obedece à rigidez das normas processuais, uma vez que, na realidade, trata-se de um ato mais confirmatório do que de reconhecimento. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Revisão nº 435.476/0 - São Paulo - 8º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos

Bonchristiano - 11.9.2003 - V. U. (Voto nº 7.487) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 29)

Nem se alegue eventual “inobservância” ao item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 que dispõe: “Entendendo o magistrado sobre a necessidade da aplicação do inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, quando da comunicação da data e horário da audiência ao estabelecimento prisional, tal circunstância será informada ao estabelecimento prisional para que além do réu, se possível, sejam apresentadas duas outras pessoas que guardem com ele semelhança”..

Por primeiro, comunicado não é lei, não substitui o Código de Processo Penal nem o regulamenta. Além disso, da leitura atenta do texto por qualquer pessoa de inteligência mediana, depreende-se que o procedimento não é obrigatório. Será utilizado apenas quando o magistrado entender necessária a aplicação do art. 226, CPP, o que não é o caso, como acima esposado.

Não bastassem as palavras da vítima, os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

O investigador Pedro, ouvido em Juízo, narrou que: “É agente policial. Participou da investigação. As informações chegaram através da vítima, que reconheceu o acusado na rua. Wesley mostrou as redes sociais de Rodrigo, onde foi possível colher a qualificação do réu. Em outra data, a vítima realizou o reconhecimento formal de Rodrigo. Se recorda de Rodrigo negar a participação no crime. Não se recorda dos detalhes informados por Rodrigo sobre onde estava na data e local dos fatos. Não conhecia o acusado anteriormente. A princípio a vítima havia reconhecido Rodrigo e um menor, porém pessoalmente reconheceu apenas Rodrigo. Não se recorda quantas pessoas havia na sala de reconhecimento, mas crê que eram três. Assistiu ao vídeo das câmeras de segurança da igreja. Não se recorda com precisão a que distância os indivíduos estavam da moto quando passaram. Não foram realizadas diligências na residência do réu para busca dos objetos da vítima”.

Seu colega Ricardo deu a mesma versão: “É agente policial. Participou da investigação. Não conhecia o acusado. A vítima procurou a delegacia com uma filmagem de câmeras de segurança e as redes sociais do réu, informando que o teria encontrado em uma barbearia próximo a igreja que frequenta. A partir das informações levadas foi possível qualificar o réu. As vítimas realizaram reconhecimento por foto. Após a prisão do acusado, foi realizado o reconhecimento pessoal na delegacia. Todos os reconhecimentos foram positivos. Rodrigo negou a participação no crime. Não se recorda os detalhes informados pelo réu sobre onde estava no dia e local dos fatos, apenas que estava em local diferente. As vítimas haviam reconhecido duas pessoas na barbearia, porém na delegacia declinaram da identificação da segunda pessoa”.

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo relatório de investigações de fls. 10/12, pelos depoimentos das vítimas, além de reiterarem os depoimentos prestados durante a fase inquisitorial.

A propósito:

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

De fato, não se vislumbra por qual motivo os policiais e as vítimas prestariam falso testemunho, incriminando injustamente o réu, pessoa que sequer conheciam até a data dos fatos.

O acusado, na Polícia, negou o delito, se forma simplista, afirmando que no horário do assalto deveria estar em casa ou com sua namorada. Entretanto, admitiu aparecer no vídeo, junto com seu cliente Leonardo, próximo à moto roubada. Disse que estavam fumando maconha, por volta das 19h, ele era seu último cliente na barbearia. Alegou desconhecer o endereço de Leonardo: "que, nego a prática do crime e, inclusive, no horário do ocorrido, eu deveria estar em casa ou com minha namorada; que, não conheço a vítima, nunca a vi.; que, no vídeo, de fato, sou eu com uma blusa cinza; que, passei junto com o meu cliente, Leonardo; que, nós fomos fumar um; que isso, foi por volta das 19h; que, ele foi o último cliente e depois eu e ele fomos fumar um baseado; não sei onde o Leonardo mora". (fls. 38).

Em Juízo, o réu voltou a negar sua participação no delito, mas deu outra versão ao álibi. Disse que no horário do assalto estava com sua namorada Yasmin em uma praça, inclusive tiraram uma foto juntos. Combinaram de se encontrarem naquela noite. Disse que, por volta das 19h, estava com Leonardo, seu cliente, na barbearia e saíram para fumar cigarro. Não "cobiçaram" a moto. Deixou Yasmin em seu apartamento por volta das 00h30, o prédio possui porteiro e câmeras de segurança. : "Tem dezenove anos. É amasiado. Não tem filhos. Estudou até o terceiro ano do ensino médio. É barbeiro. Ganha cerca de dois mil e quinhentos reais no mês. Não faz uso de entorpecentes. Não tem passagens. Não participou do assalto. No dia e horário dos fatos estava com a namorada em uma rua próxima a sua residência, em uma praça. Sua amásia se chama Yasmin. Estão juntos há um ano. Estavam na rua da lanchonete Mega Esfiha em um bairro vizinho. Tiraram uma foto juntos por volta de onze e meia da noite. Levou Yasmin para a casa do pai próximo à 00h30. Chegou em sua casa 01h15 da madrugada. A casa onde reside é próximo da barbearia e da igreja. O local onde estava no horário do assalto fica a cerca de cinco minutos da barbearia. A barbearia fica localizada na Rua Limoeiro do Norte, número 90. O apartamento onde deixou Yasmin tem porteiro e câmeras de segurança. Na delegacia informou também todos os detalhes, mas crê que foram irrelevantes para o Delegado. Leonardo é seu cliente. Reconhece que nas imagens mostradas estavam o depoente e Leonardo, porém não estavam cobiçando a moto. Estava finalizando um atendimento para ir com Leonardo na esquina fumar cigarros às 19h, pois não fuma na frente da barbearia onde trabalha. Saiu da barbearia naquele dia às 20h da noite. Leonardo foi seu último cliente. Ao sair da barbearia foi para casa tomar banho e aguardar a mensagem de Yasmin. Enquanto aguardava a mensagem foi para o outro estabelecimento do dono do salão. Buscou a namorada por volta de 23h".

Além de inverossímeis e contraditórias, as palavras do acusado encontram-se isoladas diante do conjunto probatório carreado aos autos.

Como era de se esperar, o acusado não fez nenhuma prova de seu alegado álibi, prova essa que seria de fácil obtenção, caso fosse verdadeiro.

A namorada do réu, embora evidentemente suspeita, sequer foi arrolada pela Defesa em resposta preliminar.

Da mesma forma, o tal Leonardo, "cliente" do acusado na barbearia não apresentado para corroborar suas alegações. Seria ele o comparsa o réu durante o assalto?

Obviamente, a fotografia de fls. 107 não serve como álibi, pois a geolocalização e horário de qualquer celular podem ser facilmente alterados.

Estranhamente, a Defesa não juntou a conversa em que o acusado e sua namorada combinaram o encontro naquela noite, embora o réu, em seu interrogatório tenha dito que: "Ao sair da barbearia foi para casa tomar banho e aguardar a mensagem de

Yasmin”.

Também seria simples ao acusado comprovar que deixou Yasmin na casa do pai as 00h30, já que o prédio possui câmeras de segurança e porteiro, como ele mesmo afirmou.

Interessante notar, ainda, que em sede policial o acusado afirmou que estava fumando um “baseado” (maconha) com Leonardo do lado de fora da barbearia quando apareceu nas câmeras de segurança da igreja. Em Juízo, entretanto, o acusado negou o uso de entorpecentes, afirmando que era cigarro.

Aliás, no vídeo das câmeras de segurança, cujo link foi apresentado pela própria Defesa às fls. 112 da resposta escrita, é nítido que o acusado observa detidamente a moto da vítima, como quem a “cobiça”, exatamente como descrito por Wesley em seu depoimento.

Como se vê, além de não comprovada, a negativa do acusado não merece ser levada em conta, isto porque nada trouxe que afastasse dele a responsabilidade pela subtração ora apurada, limitando-se a fazer alegações vagas e sem elementos probatórios que as comprovassem, ao contrário das narrativas trazidas pelas vítimas e testemunhas, que apresentam sequência lógica e coesa.

Não há dúvida, portanto, quanto à participação do acusado no assalto narrado na denúncia.

As causas especiais de aumento de pena referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes devem ser reconhecidas.

O concurso de agentes restou indubitável diante da narrativa das vítimas.

Embora não apreendida a arma de fogo utilizada no assalto, as vítimas foram categóricas ao narrar que o acusado estava armado no momento da abordagem.

A palavra firme e segura da(s) vítima(s), no delito de roubo, basta para o reconhecimento das aludidas majorantes.

A propósito:

STJ “Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima” (RT 841/515)

STJ “É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do artigo 157, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima” (RT 821/534).

Embora existam duas majorantes comprovadas nos autos, somente é possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

A segunda majorante, relativa ao concurso de agentes, somente pode ser considerada na dosagem da pena como circunstância do delito, nos termos do art. 59, CP.

Convém lembrar, a Lei n. 13.654/18 não padece de inconstitucionalidade formal.

Na verdade, como se verá a seguir, houve equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Trata-se, portanto, de mera irregularidade, que não tem o condão de viciar o processo legislativo.

A mens legislatoris desde sempre foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal objetivo foi, de fato, alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Artigo publicado no site "Só Notícias" da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Procurador de Justiça (MP/MT), explica minuciosamente o equívoco cometido e que gerou toda a celeuma em torno do art. 4º, da Lei n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaio/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, designadamente no que concerne ao seu artigo 4º, o qual revogou a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Como já se sabe, o aludido diploma normativo, entre outras inovações inseridas no Estatuto Repressivo, introduziu o § 2º-A ao artigo 157 (tipo penal de roubo), aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços) quando o delito envolve o emprego de arma de fogo e na hipótese em que há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, no cometimento da infração. Por outro lado, o novel diploma legal, como dito, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, que aumentava em 1/3 (um terço) a pena quando a violência ou ameaça fosse exercida com o emprego de arma (lato sensu), abrangendo, pois, todo e qualquer artefato possível de ser utilizado para a defesa ou ataque, seja ele próprio (revólver, faca, espada, etc.) ou impróprio (pedra, barra de ferro, porrete, etc.).

Contudo, na aurora da vigência da novel lei, alguns estudiosos têm apontado um suposto vício de constitucionalidade no referido documento normativo. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento recente, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. A ementa do julgado é a seguinte:

TJSP: "ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO TENTADO - APELAÇÃO - Pleito Ministerial de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma (branca) - Superveniência da Lei posterior extirpando o inciso I do §2º do art. 157 do CP - RECONHECIDA a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018 - SUSPENSO o julgamento do mérito do recurso e DETERMINAÇÃO da instauração de incidente de inconstitucionalidade com remessa ao Órgão Especial para apreciação, nos termos do art. 193 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça". (Apelação Criminal com Revisão nº 0022570-34.2017.8.26.0050. Quarta Câmara Criminal. Rel. Des. Edison Brandão. Data de Julgamento 08/05/2018).

Inclusive, na esteira desse entendimento, as Chefias dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo (04), de Mato Grosso do Sul e Goiás⁶, recomendaram aos

membros das respectivas Instituições, ainda que de maneira não vinculante, que, em sede de controle difuso, arguissem a inconstitucionalidade formal do preceito normativo que revogou a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, uma vez que, segundo argumentam, haveria afronta ao devido processo legislativo na tramitação do Projeto de Lei (PLS 149/2015) que resultou na promulgação da Lei 13.654/2018.

Em síntese, sustenta-se que no texto final do PLS 149/2015, aprovado, inicialmente, pelos senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não constava qualquer dispositivo revogando a majorante do emprego de arma (lato sensu) conforme, depois, constou no artigo 4º da Lei 13.654/2018. Afirma-se, inclusive, que a CORELE (Coordenação de Redação Legislativa) do Senado Federal foi quem, indevidamente, inseriu o dispositivo no Projeto de Lei, em desacordo com aquilo que havia sido, efetivamente, aprovado pelo plenário daquela comissão, e que, posteriormente, a proposta legislativa seguiu em sua tramitação regular, levando consigo aquele vício, até sua promulgação, configurando, desse modo, a inconstitucionalidade formal por suposta afronta ao disposto no artigo 65 da Constituição Federal.

Contudo, conforme será demonstrado a seguir, a celeuma toda decorreu de um equívoco cometido pelos responsáveis pela publicação no Diário do Senado Federal da matéria aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, para bem demonstrar esse lapso, importa promover aqui uma análise detalhada da tramitação do projeto de lei, a partir de consulta nos websites do Senado (07) e da Câmara Federal (08), algo que poderá ser entediante, porém necessário.

Pois bem. Consta que no dia 24/03/2015, foi protocolado o Projeto de Lei do Senado nº 149/2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que, a um só tempo, criava, de um lado, duas novas causas de aumento de pena na hipótese de crimes de roubo, quais sejam, quando durante a prática criminosa houvesse o emprego de arma de fogo ou se fosse constatada a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 1º) e, por outro lado, revogava a majorante inculpada no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, que se referia ao roubo cuja violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma (art. 3º)⁹. Importante notar, prontamente, que desde a proposta inicial estava clara e taxativa a intenção de derrogar a cogitada causa de aumento de pena anteriormente prevista no Código Penal.

O projeto, que tramitou na forma do art. 91, §§ 3º a 5º do Regimento Interno do Senado Federal, depois de protocolado, foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde o relator, Senador Antonio Anastasia, emitiu parecer pela aprovação da proposta (10), tal qual apresentada pelo proponente.

A matéria foi incluída na pauta da CCJ e, então, na sessão do dia 13/09/2017, após a leitura do relatório do Senador Antonio Anastasia, foi concedida vista do projeto aos Senadores Eduardo Amorim e Vanessa Grazziotin. Não houve, portanto, naquela sessão, qualquer deliberação a respeito do mérito do projeto de lei (11).

A matéria voltou à pauta da sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ocasião na qual a Senadora Simone Tebet apresentou a Emenda Aditiva nº 0112, que, a rigor, nada alterou a proposta original no ponto em que revogava a majorante inculpada no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Naquela mesma sessão, o Senador Antonio Anastasia reformulou seu relatório, acolhendo a emenda que foi proposta, e, posteriormente, o plenário da cogitada comissão aprovou¹³ o texto do Projeto de Lei – Parecer (SF) 141/2017¹⁴ –, tal qual formulado pelo seu proponente, com o acréscimo da citada emenda apresentada pela Senadora sul-matogrossense.

Contudo, o Parecer (SF) nº 141/2017, ao ser publicado no Diário do Senado Federal

(15), certamente por algum lapso, não trouxe em seu texto o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa, conforme já foi dito, a revogação do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Aqui, aparentemente, repousa o ponto nodal de toda a celeuma, qual seja, o descompasso entre o que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e o texto publicado no Senado Federal, que, repita-se, não retratou aquilo que foi deliberado.

Fato é que, na sequência, o PLS 149/2015 foi encaminhado à CORELE (Comissão de Redação Legislativa), que, ao que consta, recebeu o texto, precisamente, como aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, isto é, contendo o dispositivo que revogava a majorante que tratava do emprego de violência ou ameaça exercida com emprego de arma (lato sensu) (16).

Posteriormente, o texto aprovado (17), que continha a revogação da majorante, e, porquanto, tal qual, efetivamente, deliberado pelo Senado Federal, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde foi convertido no PL 9.160/2017, ao qual se apensou o PL 5.989/2016, de autoria do Deputado Severino Ninho, que já trazia apensado o PL 6.737/2016, que veiculava uma outra proposta legislativa que foi, então, acrescida à proposta vinda da Casa da Federação (18).

Mais à frente, o Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei tal qual encaminhado pelo Senado Federal, acrescido, apenas, de um artigo que dispôs acerca da inutilização de cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas eletrônicos em caso de arrombamento (19). Isto quer dizer que a única alteração material feita pela Câmara dos Deputados nada disse respeito à revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Aliás, a derrogação da aludida causa de aumento de pena, constante na proposta vinda do Senado de República, manteve-se intocável, e restou prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017, aprovado pela Casa Revisora.

Em seguida, no dia 06/03/2018, o Projeto de Lei – que, naturalmente, continha a revogação da majorante em seu artigo 4º – sob a rubrica de Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, retornou à Casa Iniciadora (20) onde foi aprovado pelo Plenário21.

Empós, como de rigor, encaminhou-se o texto aprovado para a sanção do Presidente da República, sendo que, posteriormente, houve a promulgação da lei aprovada22.

Como se pode ver, a revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, além de constar no texto original do PLS 149/2015, permaneceu no Texto Final aprovado pela CCJ no Senado Federal, depois, constou no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal.

Portanto, à guisa de conclusão, impõe-se reconhecer que a apontada inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018 se baseia num equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que, como visto, não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Tal equívoco, que há de merecer o timbre de mera irregularidade, não tem o condão de viciar o processo legislativo, ao ponto de se ter como inconstitucional o sobredito preceito. A propósito, é de ver que a mens legislatoris desde sempre, foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal desiderato, ao final e ao cabo, foi alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Convém registrar, por último, que, apesar de não conter qualquer vício de

constitucionalidade formal, o artigo 4º da Lei 13.654/2018, representa, inequivocamente, grave redução no nível de proteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal, pois, afinal, a experiência aponta, ao sobejo, que o crime de roubo, comumente, é praticado tanto com armas de fogo, como também com o emprego de outras armas – próprias ou impróprias –, circunstância que, além de diminuir a possibilidade de reação da vítima, eleva a potencialidade da ameaça e da violência.

Assim, ante esse decréscimo do nível de proteção, abre-se a possibilidade de se questionar eventual violação do Princípio da Proporcionalidade na perspectiva da Proibição de Proteção Deficiente. Mas, claro, esse é um outro lado da moeda e, porquanto, há de ser discutido oportunamente.

Domingos Sávio de Barros Arruda – Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Procurador de Justiça (MP/MT).

Victor Lucas Alvim – Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Oficial de Gabinete (MP/MT).

03. <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RI0046PXE00000#?cdDocumento=35> . Acesso em 16 maio 2018.

04. <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/COMUNICADO%20CAOCrim%20AVISO%20162%202018.docx> . Acesso em 16 maio 2018.

05. <https://www.mpms.mp.br/noticias/2018/05/procurador-geral-de-justica-do-mpms-aponta-inconstitucionalidade-em-lei-que-extingue-majorante-de-roubo-com-arma> . Acesso em 16 maio 2018.

06. <http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/nota-tecnica-do-mp-alerta-para-vicios-em-artigo-de-lei-que-altera-punicao-de-crime-com-uso-de-explosivo#.WwMXg-7RWM8> . Acesso em 21 maio 2018.

07. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/120274> . Acesso em 16 maio 2018.

08. <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149> . Acesso em 16 maio 2018.

09. O arquivo pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-etter/documento?dm=3599802&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

10. O arquivo pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=3599811&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

11. Trata-se da 37ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?5&reuniao=6590&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h37min15seg até 01h40min43seg do vídeo.

12. O arquivo pode ser encontrado no seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

13. Trata-se da 49ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?0&reuniao=6919&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h00min até 01h18min do vídeo.

14. No website do Senado Federal, na seção “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, pode-se fazer o download do Parecer (SF) Nº 141, de 2017, no qual

se tem o Parecer do relator, a Emenda aditiva, o Relatório de Registro de Presença da CCJ naquela data, a Lista de Votação Nominal, o Texto Final aprovado e a Decisão da Comissão. Conferir o seguinte link:<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

15. O Parecer (SF) Nº 141, de 2017, quando publicado no Diário do Senado Federal do dia 10/11/2017 (páginas 133 a 143) não trouxe, no Texto Final aprovado pela CCJ, o dispositivo revogador da malfadada majorante (conferir, designadamente, as páginas 141 e 142). O Diário Oficial do Senado do dia 10 de novembro de 2017 pode ser baixado no seguinte link: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=10/11/2017&paginaDireta=00133#> . Acesso em 16 maio 2018.

16. Este órgão, ao que tudo indica, recebeu o texto que consta no site do Senado Federal, na seção de “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, ou seja, o texto com a revogação da majorante, efetivamente aprovado pelos parlamentares. Conferir: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

17. <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7275778&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

18. O projeto apensado previa “que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que colocarem a disposição do público caixas eletrônicos, instalem equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco, alta temperatura, e dá outras providências”. Conferir: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2121517> . Acesso em 16 maio 2018.

19. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados pode ser baixado no seguinte link: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1642561&filename=Tramitacao-PL+9160/2017 . Acesso em 16 maio 2018.

20. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/132413> . Acesso em 16 maio 2018.

21. Nessa ocasião, a aprovação se deu após a leitura de parecer favorável da lavra do Senador Dário Berger (Parecer nº 51, de 2018 – PLEN/SF, em substituição à CCJ). O parecer pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7652589&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018. O texto final aprovado pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7653672&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

22. O texto pode ser baixado no seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7653672&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.”

É o que ocorre quando analfabetos funcionais se metem a fazer e/ou alterar leis em nosso país.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhes as penas.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, as circunstâncias, as consequências e a gravidade (em concreto) do delito, bem a personalidade deformada do réu. Com efeito, o acusado, junto com seu comparsa, abordou as vítimas em plena via pública, após premeditarem o crime, causando

prejuízo material estimado em sete mil reais.

Face à atenuante da menoridade, retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Nos termos do art. 59, c.c. os artigos 311, 312 e 387, parágrafo único, do Estatuto Adjetivo, considerando a extrema gravidade do ilícito praticado (em plena via pública, durante a tarde, com utilização de arma de fogo e comparsaria com outro indivíduo que conseguiu fugir), que é daqueles que mais atingem e intranquilizam as populações ordeiras, notadamente nesta Comarca, onde já se tornou verdadeiro flagelo de proporções alarmantes, portanto a merecer repressão exemplar, deixo de lhe conceder quaisquer benefícios, inclusive o de recorrer em liberdade, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal em regime fechado, o mais compatível com sua periculosidade e forma de proceder.

A fixação de regime mais brando ao acusado seria desproporcional à conduta, desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, I E II). FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. A alegação de que o regime prisional mais gravoso foi fixado com base na gravidade em abstrato do crime não encontra fundamento, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, o que, inclusive, motivou o aumento da pena-base. Inteligência do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, caput e inciso III, ambos do Código Penal. Ordem denegada. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 88493 - JULGAMENTO: 30/05/2006)

"O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário. "Habeas corpus" indeferido. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 74301 - ACÓRDÃO MESMO SENTIDO: HC 68988 ANO-1991 UF-SP TURMA-02 N. PP-012 Min. MARCO AURÉLIO DJ 24-09-1999 PP-00026 EMENT VOL-01964-01 PP-00202 RAC-MIN-CARLOS VELLOSO - JULGAMENTO: 29/10/1996)

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno RODRIGO SOARES LEITE, já qualificado, por incurso no art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir em estabelecimento adequado, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, calculado o valor unitário das penas pecuniárias no mínimo.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está;

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - remessa de cópia desta decisão às vítimas, com endereço nos autos;

II - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a imediata transferência do mesmo para o regime prisional imposto;

III - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

P.R.I.C.

Guarulhos, 23 de junho de 2022.